

1500133-27.2021.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Comarca: Presidente Epitácio

Foro: Foro de Presidente Epitácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... dele foram apreendidos. Dada, então, a voz de prisão por tráfico de drogas e encaminhado Reginaldo à delegacia de polícia e o delegado que recebeu a ocorrência decidiu por lavrar auto de prisão em flagrante. Sim, não teve participação direta na investigação: a finalidade da operação visava apurar tráfico e associação para tráfico e ele era um dos investigados. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Epitácio

Foro de Presidente Epitácio

1ª Vara

Av. Presidente Vargas 1-31, Presidente Epitacio - SP - cep 19470-000

1500133-27.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-27.2021.8.26.0585 - Feito nº 2021/001709

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO ZUQUI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Vistos.

O Ministério Público, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste juízo e no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, tombado sob o nº 2178608/2021, ofereceu denúncia em face de Reginaldo Zuqui, devidamente qualificado às fls. 08, dos autos deste processo crime, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela prática dos fatos delituosos, narrados na peça vestibular, nos seguintes termos: Consta da denúncia que, no dia 02/07/2021, por volta das 06h20min, na Rua Belém, 3272, Jardim Real I, nessa cidade e Comarca, Reginaldo Zuqui estaria guardando, para entrega a consumo de terceiros, sete porções de Cannabis sativa L., pesando 672,00 gramas, droga capaz de causar dependência física ou química, sem autorização legal ou regulamentar.

Dispensada a realização da audiência de custódia com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no supramencionado artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020 e no Provimento CSM nº 2.549/2020, que estabeleceu o Sistema Remoto de Trabalho em virtude da pandemia de covid-19, o Ministério Público, em manifestação, pugnou pela homologação da prisão em flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva (fls. 75-81).

A N. Defesa constituída pelo acusado, deixou transcorrer o prazo para manifestação (fls. 82).

Homologado o auto de prisão em flagrante, foi convertida a prisão em flagrante do denunciado em prisão preventiva na data de 03/07/2021 (fls. 83-89).

Determinou-se a redistribuição do feito por dependência ao inquérito policial de nº 1500497-20.2021.8.26.0481, porquanto o deferimento da busca e apreensão domiciliar

fez o Juízo da 2ª Vara Criminal local se firmasse prevento (fls. 135-136). Pedido de revogação da prisão preventiva, após manifestação contrária do ilustre representante do Ministério Público, indeferido em (fls. 101-106; 130-132; 141 e 142-145).

O Juízo da 2ª Vara Criminal desta comarca declinou da competência, nos termos do artigo 83 e 76, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 175-176).

Suscitou-se conflito negativo de competência, com fulcro no artigo 114, inciso II, c/c artigo 115, inciso III, ambos do Código de Processo Penal (fls. 179-182).

Impetrado Habeas Corpus com pedido liminar ao E. STJ, a cautela alvitrada foi indeferida (fls. 185-188).

A prisão preventiva do acusado foi reavaliada e mantida em 30/09/2021 (fls. 202-203).

Pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelo fato do acusado ser imprescindível ao cuidado dos filhos menores, após manifestação contrária do ilustre representante do Ministério Público, indeferido em 11/10/2021 (fls. 207-210; 218-219; e 221).

Pedido de instauração de incidente de dependência químico-toxicológica, após manifestação Ministerial pelo indeferimento do pedido (fls. 2325-228, 232-235)

Nos termos do disposto no art. 316, § único, do Código de Processo Penal, com a alteração promovida pela Lei 13.964/2019, bem como em razão da orientação dada pelo Comunicado CG nº 78/2020, foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do acusado (fls. 276-278).

O acusado constituiu novo Defensor (fls. 287-288) e ofertou defesa prévia, momento em que pugnou pela revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 292-318).

A i. Representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão preventiva do acusado (fls. 323-324) e o pedido da N. Defesa foi indeferido (fls. 325-326).

Decidido o conflito de jurisdição no sentido de que este é o juízo competente para conhecer e processar a presente ação (fls. 332-339), deu-se o acusado por notificado (fls. 344).

A denúncia foi recebida em 20/01/2022, ocasião em que foi rejeitada a hipótese de absolvição sumária, revogada a prisão preventiva do acusado e, considerando a gravidade da situação, em virtude da pandemia de COVID-19 e das recomendações dos órgãos de saúde pública para o máximo isolamento social, a fim de se prevenir a propagação do contágio e visando resguardar a saúde dos presentes, com fundamento no comunicado CG nº 250/2020, no artigo 8º, caput, da Recomendação CNJ nº 62/2020, em caráter excepcional, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams (fls. 370-375).

O Alvará de soltura foi devidamente cumprido em 21/01/2022 (fls. 391-394).

Prosseguiu-se, então, à fase instrutória, momento em que foram ouvidas cinco testemunhas.

O pedido de compartilhamento das provas dos autos 1500497-20.2021.8.26.0481 que deram origem aos mandados de busca e apreensão foram indeferidos e designou-se audiência em continuação para oitiva de uma testemunha do juízo (fls. 415-417). Laudos de exame químico de entorpecente e do aparelho celular apreendido acostados (fls. 431-433 e 434-470).

A testemunha do juízo foi inquirida e, ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal as partes nada requereram.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu, já que comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

A Defesa, por seu turno, pugnou, preliminarmente, sejam declaradas nulas as provas produzidas em decorrência da busca e apreensão realizada na residência do acusado, pois a interceptação telefônica teria sido iniciada em 11/06/2021, nos autos 1500497-20.2021.8.26.0481, e a mandado de busca e apreensão teria sido deferido em 25/06/2021. No mérito, postulou pela absolvição do acusado e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico para o descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 e, ainda, por benefícios no tocante à pena.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há falar em prova ilícita ou ilegítima.

Os relatos do delegado de polícia Márcio Domingos Fiorese foram claros e uníssonos no sentido de que "Em julho de 2020, o Aureliano foi autuado em flagrante logo após ter vendido duas porções de maconha e estar na posse de outras três em situação indicativa de mercancia. Com autorização judicial, foi feita análise técnica dos dados telemáticos do celular dele – especialmente os diálogos por whatsapp dele, sobretudo os áudios, indicavam que Aureliano estaria, em tese, associado a outras pessoas, para fins de tráfico. Uma delas seria o Dino, o atual réu, Reginaldo Zuqui".

Observe que a quebra do sigilo da dados telefônicos (CF, art. 5º, X), objeto dessa representação, não se confunde com a interceptação telefônica, prevista no inciso XII do mesmo artigo e regulamentada pela Lei 9.286/96.

Na quebra do sigilo de dados telefônicos se busca os elementos referentes aos titulares das linhas, aos numerais de IMEI, aos Sim Cards ("chips"), às ligações efetivadas e recebidas por tal ou qual linha telefônica (informações pretéritas). Já na interceptação telefônica se pretende a captação da conversação telefônica atual, presente.

Nesse sentido leciona o Ministro Gilmar Mendes:

[...] não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.º 91.867/PA. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília /DF: DJ 24.04.2012).

É assente na doutrina e na jurisprudência que a garantia do sigilo de dados referente a linha telefônica do investigado, por não ser absoluta, pode ser afastada quando estiver sendo utilizada para ocultar a prática de atividades ilícitas.

Assim, excepcionalmente, quando tais dados se mostrarem indispensáveis e exista fundados elementos de suspeita que se apoiem em indícios idôneos, reveladores de possível autoria de prática criminosa, como no caso dos autos, é admitida a quebra do sigilo, que fora regularmente deferida nos autos 1500528-74.2020.8.26.0481 e integram os autos 1500497-20.2021.8.26.0481.

No mérito, trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar a responsabilidade de Reginaldo Zuqui pela prática do fato delituoso disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, porquanto, como se verá a seguir, de rigor a desclassificação do delito de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal.

Assim, procedo à emendatio libeli, na forma do art. 383 do CPP, para capitular a conduta no referido dispositivo legal.

A materialidade do delito de porte para consumo pessoal está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (fls. 04-05), boletim de ocorrência (fls. 10-16), auto de exibição e apreensão (fls. 19-21), auto de constatação da natureza tóxica (fls. 22-23), laudo pericial do aparelho celular apreendido (fls. 434-470) e laudo pericial químico de entorpecente (fls. 431-433), que atestou que a substância detectada se tratava de Cannabis sativa L., que é de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por seu turno, é inconteste, por intermédio da prova oral coligida em Juízo, e é atribuída ao acusado Reginaldo Zuqui.

O delegado de polícia responsável pelas investigações, senhor CLÁUDIO MIGUEL, foi ouvido como testemunha compromissada em audiência de instrução, debates e julgamento: "Correto. Nesse dia, foi deflagrada uma operação de investigação que já havia sido feita pela Delegacia. Minha função foi dar cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de Reginaldo e ao mandado de busca em sua residência. Nossas equipes deram, então, cumprimento aos dois mandados. Fomos recebidos pelo Reginaldo: nos fundos da casa, em um quartinho, estavam sete porções grandes de maconha em uma mochila, já embaladas em sacos plásticos, R\$ 390,00, uma faca e um rolo de papel filme. No interior da casa, dois telefones de uso dele foram apreendidos. Dada, então, a voz de prisão por tráfico de drogas e encaminhado Reginaldo à delegacia de polícia e o delegado que recebeu a ocorrência decidiu por

lavar auto de prisão em flagrante. Sim, não tive participação direta na investigação: a finalidade da operação visava apurar tráfico e associação para tráfico e ele era um dos investigados. Relação de amizade, não tenho, mas sei quem é ele. Sim, a família dele, o irmão dele trabalhava em açougue com ele e, atualmente, tem uma pizzaria. Que tenha chegado ao meu conhecimento, não, mas ressalvo que a investigação não foi conduzida por mim que só auxiliei nos trabalhos de cumprimento. Durante as diligências, em contato pessoal, ele alegou ser usuário de entorpecentes”.

Depoimento em tudo corroborado por seu colega, o senhor SANDRO MARCELO DE SOUZA GEA, ouvido nas mesmas condições: “Eu sou investigador de polícia de Caiuá e fui convocado para uma operação policial deflagrada em 02 de julho de 2021. Integrei uma equipe liderada pelo dr. Cláudio: cumprimos mandados de busca em residência e de prisão temporária – foram encontrados em sua casa R\$ 390,00 em dinheiro, uma faca, papel filme, 7 porções grandes de maconha embalada, dois cachimbos e dois celulares. As investigações prévias foram feitas por policiais da delegacia de Epiitácio. Assumiu a propriedade dos entorpecentes e disse que seria usuário. Foi conduzido à delegacia e, na ocasião, o delegado o autuou em flagrante por tráfico de drogas. Não me recordo se ele explicou a origem do dinheiro, só sei que o dinheiro foi apreendido no mesmo lugar em que estava a droga: em um quarto, nos fundos da residência”.

Pela defesa, EDER FERNANDES PEREIRA (testemunha compromissada) ponderou que: “Sou amigo dele, de trabalho, há algum tempo, nos conhecemos no Super Neto. Não, algumas poucas vezes nos víamos, como a mãe dele morava ali perto da minha casa, ali no cemitério, em horas vagas, poucas vezes, nos víamos. Fora isso, era rotina do trabalho. Através de colegas nossos soube o que aconteceu, fiquei até sem entender. Ele era consumidor, já consumimos, mas isso de vender droga assim, eu nunca soube. É pai de família, trabalhador, cara do bem, até a esposa dele a gente conhece”.

Por sua vez, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS disse que: “Sou amigo dele, moramos no mesmo bairro, bem próximo, durante vinte e nove anos e o conheci através de outros amigos. Raramente, assim. Isso. Não, nunca o vi vender drogas. Com certeza (saberia se o acusado fosse traficante de drogas). Sim, usuário sim”.

Já a informante ANA PAULA OLIVEIRA SILVA ZUQUI contou que: “Sim. Ele é usuário de maconha desde que o conheci, estamos juntos, entre casamento e namoro há mais de 16 anos. Em pouco tempo de namoro ele já me disse que era usuário de maconha. Não, nunca me causou mal, não concordo, mas ele é honesto, trabalhador, bom pai de família. Acredito que o mal maior é para ele mesmo, mas isso nunca me prejudicou. No fundo da casa, no quarto de despensa, ele armazenava lá, ele sempre deixava na chave, fechado, usava droga nos fundos, não na nossa frente, na parte da noite, acordava de madrugada para fumar. Ah, com certeza em casa: esse é um dos motivos pelos quais aceitava, apesar de não concordar, preferia que ele usasse nos fundos, trancado, sem ninguém ver, sem se expor ao julgamento das pessoas nem confusão sobre seu vício. Nunca o presenciei vender drogas para ninguém. Ah, a vizinha reclamava do cheiro, porque a casa dela ficava próxima do quarto onde ele fumava. O dinheiro encontrado era da venda das rosas do deserto, porque fazemos renda extra vendendo mudinha, deserto e o dinheiro era deixado em separado”.

MÁRCIO DOMINGOS FIORESE, Delegado de Polícia, afirmou que “Sim, senhora. Em julho de 2020, o Aureliano foi autuado em flagrante logo após ter vendido duas porções de maconha e estar na posse de outras três em situação indicativa de mercancia. Com autorização judicial, foi feita análise técnica dos dados telemáticos do celular dele – especialmente os diálogos por whatsapp dele, sobretudo os áudios, indicavam que Aureliano estaria, em tese, associado a outras pessoas, para fins de tráfico. Uma delas seria o Dino, o atual réu, Reginaldo Zuqui: que ali restou apontado como associado ao Aureliano para tráfico de drogas. Foram feitas pesquisas, então, em autos apartados e com autorização judicial, foi feita a busca na casa do Reginaldo, onde foram encontradas as drogas e dois aparelhos celulares do Reginaldo: um deles, inclusive, era a mesma linha que ele usava para falar com o Aureliano.

Interrogado, o acusado Reginaldo Zuqui negou a prática delitiva, dizendo que “Sim, sim, gostaria de falar: desde os 12 anos, sou usuário: sempre usei maconha. O que foi encontrado ali era do meu consumo – havia pegado há pouco tempo. O dinheiro

encontrado era do meu trabalho, sempre trabalhei vendendo rosas do deserto e adubo. Ela estava porcionada já para mantê-la e fazer o meu consumo semanal. Sim, eu sempre comprava meio quilo, tinha medo de ser abordado pela polícia, então, para evitar ir à biqueira ou à boca, sempre preferi comprar grandes quantidades. Eu levava como uma vida liberada, sempre fiz assim, mesmo sabendo que era errado. Fumava de 12 a 15 gramas por dia – de 10 a 12 cigarros por dia. Sempre fui amigo do Aureliano, com quem sempre fumei junto e sou amigo desde o colégio. Talvez tenham achado que tivéssemos alguma ligação, mas nada além da amizade, sempre só fumando junto. Não, nunca vendi. Não sei falar da vida pessoal dele. Sim, a gente mandava fotos um para o outro sim. A gente sempre pergunta quem tem um bom, sempre passamos a informação de quem tem um bom, sempre já fumei, mas passar drogas para amigos, nunca. Olha, trabalho desde 2006 – saí em 2013 e retornei em 2014. Fui dispensado no mês nove do ano passado e voltei para a mesma empresa agora, depois da prisão. Sim, ele trabalha comigo esse rapaz, não foi sobre droga não, doutora. Agora, o que era, no momento, não me lembro; ele é açougueiro, se chama Gabriel e trabalha comigo. Não, doutora. Hoje ganho o valor de R\$ 2.400,00; tenho dois meninos: um de 10 anos e outro de 4 anos. Moram comigo. Doutora, na época, paguei R\$ 650,00 o meio quilo. Duraria em torno de três a quatro meses, doutora".

A par da confiabilidade que se deposita nos agentes públicos, que gozam da presunção iuris tantum de veracidade, tenho que os depoimentos prestados não apresentaram indícios efetivos da traficância, mas, apenas, que o acusado detinha em seu poder certa quantidade de entorpecentes, uma faca e um rolo de papel filme. Ademais, embora a quantidade da droga apreendida seja expressiva, não foram localizadas balança de precisão e anotações relacionadas à contabilidade pela venda de entorpecentes. Também não há depoimentos de eventuais usuários e outros elementos indicativos da mercancia de entorpecentes, porquanto o laudo pericial realizado no aparelho celular do acusado apresenta apenas conversas típicas de usuários.

Por outro lado, juntamente com os entorpecentes foram apreendidos dois cachimbos, o que fortalece a alegação do acusado de que é usuário contumaz de maconha, a qual está corroborada pelos relatos dos informantes do juízo.

Assim, fica a acusação de tráfico de drogas permeada de dúvidas, o que inviabiliza a prolação de um decreto condenatório neste sentido.

Por outro lado, certo é que o réu admitiu a propriedade da droga, sendo de rigor, assim, a sua responsabilização pela posse para o uso pessoal das drogas ilícitas, impondo-se, assim, a desclassificação.

Frise-se que, apesar de a lei ter encampado as políticas criminais de redução de risco, da justiça terapêutica e restaurativa, não houve a intenção do legislador de descriminalizar a posse de drogas para consumo pessoal. Prova maior desta afirmação é que enquadrou esta modalidade de conduta no Capítulo III da Nova Lei de Entorpecentes, que trata dos crimes e das penas.

Assim, revela-se, de forma clara, a intenção do legislador de capitular a posse de drogas para consumo pessoal como uma das figuras criminosas da lei em análise.

Na realidade, tais condutas continuam a ser consideradas criminosas, porque a mencionada Lei de Introdução ao Código Penal (art. 1º) foi cunhada para se harmonizar com o estabelecido pelo Código Penal que se encontra em vigor, o qual, na redação atual de seu art. 32 estabelece que as penas são: privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa, incluindo, dessa forma, as penas previstas para o delito em apreço.

Não há dúvida de que a questão das drogas também envolve políticas públicas e que deveriam ser tomadas outras medidas para propiciar o tratamento do vício. Por outro lado, o porte para uso próprio certamente causa risco à sociedade e à saúde pública, sendo considerado fato típico e merecedor de resposta na esfera penal. Prevê a Lei de Tóxicos, no caso de guarda e porte de entorpecente para o consumo pessoal, as penas de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo.

Considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, por não ostentar maus antecedentes (fls. 69), reputo adequada a pena de advertência.

DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta

tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e CONDENAR REGINALDO ZUQUI, já qualificado nos autos desse processo crime, como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06, à pena de advertência dos efeitos nocivos da droga.

Observando-se o artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sobretudo pela quantidade de reprimenda corporal aplicada e porque ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de elementos que viabilizem a fixação de um patamar mínimo de reparação dos danos causados pela infração e diante da ausência de pedido.

Condeno o réu nas custas processuais.

Considerando que foram apreendidos nos autos R\$ 390,00 e dois aparelhos de telefone celular (auto de exibição e apreensão de fls. 20-21), autorizo, pelos fundamentos externados nesta sentença, a restituição dos valores ao réu ou à pessoa por ele indicada, mediante pedido expresso.

Quanto aos demais objetos apreendidos (auto de exibição e apreensão de fls. 20-21), por estarem diretamente relacionados à prática delitiva, declaro o seu perdimento em favor da União e autorizo a destruição, dada à inexpressividade de seu valor econômico.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências:

Autorizo a incineração da substância entorpecente remanescente, guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06;

Em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se o órgão competente para o recolhimento dos bens apreendidos, de acordo com artigo 63, § 2º, da Lei 11.343/06;

Oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Intime-se o(a) sentenciado(a), ressalvada a hipótese de ser beneficiário(a) da justiça gratuita, para efetuar o recolhimento do valor das custas processuais, no valor de 100 UFESP's, no prazo de 10(dez) dias.

Expeça-se mandado de intimação para que o Sr. Oficial de Justiça intime o réu da advertência dos efeitos nocivos do consumo de entorpecentes.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

Publique-se.

de Presidente Epitácio, 03 de junho de 2022

MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO(A) MAGISTRADO(A), NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.